PROVA ORAL · MAGISTRATURA · BLOCO 5

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITOS HUMANOS

Direito Constitucional e Direitos Humanos

1. Visão Geral e Mapeamento dos Eixos Temáticos

Nas provas orais da Magistratura Estadual, **Direito Constitucional e Direitos Humanos** formam um eixo indissociável de avaliação, testando se o candidato possui a **leitura constitucionalizada dos ramos do direito** e o domínio da **jurisdição constitucional e internacional**. As bancas medem a capacidade do candidato de operar o duplo filtro de validade das normas (controle de constitucionalidade + controle de convencionalidade).

Os cinco grandes eixos temáticos exigidos pela banca compreendem:

1. **Controle de Constitucionalidade e Jurisdição Constitucional**: Distinção entre controle difuso-incidental e concentrado-abstrato; Bloco de Constitucionalidade; Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante 10); modulação de efeitos temporal das decisões (quórum de 2/3); e os limites da mutação constitucional.
2. **Direitos e Garantias Fundamentais em Colisão**: Proporcionalidade e razoabilidade (ponderação de Robert Alexy); liberdade de expressão vs. direitos da personalidade; tese da **incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" com a CF** (Tema 786/STF); e inconstitucionalidade da "legítima defesa da honra" (ADPF 779/STF).
3. **Incorporação dos Tratados e Controle de Convencionalidade**: Rito qualificado do art. 5º, § 3º, da CF (equivalência a Emenda Constitucional) vs. rito ordinário (status supralegal - RE 466.343/STF); paralisação da eficácia da prisão civil do depositário infiel (Súmula Vinculante 25); e a Teoria do Duplo Filtro de Validade Normativa (Mazzuoli).
4. **Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)**: Tutela constitucional dos Direitos Humanos (art. 109, § 5º, da CF); requisitos constitucionais e jurisprudenciais do STJ; legitimidade ativa exclusiva do Procurador-Geral da República; e a federalização de investigações/processos em caso de grave violação a direitos humanos.
5. **Responsabilidade Internacional do Estado e Sentenças da Corte IDH**: Jurisprudência vinculante da Corte Interamericana de Direitos Humanos; obrigações de reparação e não repetição; casos emblemáticos com condenação do Brasil (*Caso Márcia Barbosa*, *Damião Ximenes*, *Favela Nova Brasília*, *Fazenda Brasil Verde*, *Guerrilha do Araguaia/Julia Gomes Lund*); e a eficácia executiva das sentenças da Corte IDH no foro interno (art. 68.1 da CADH).

2. Mapeamento Exaustivo das Perguntas Frequentes da Banca

Eixo A: Controle de Constitucionalidade e Reserva de Plenário

- **Súmula Vinculante 10 e Reserva de Plenário**: *"Candidato, o que estabelece a Súmula Vinculante nº 10 do STF? Se uma Turma Cível ou Criminal de um Tribunal de Justiça afastar a incidência de uma lei sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, há violação à Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF)?"*.
- **Modulação de Efeitos no Controle Difuso**: *"É possível ao Supremo Tribunal Federal realizar a modulação temporal dos efeitos de uma decisão proferida em sede de controle difuso de constitucionalidade? Qual o quórum exigido e o fundamento legal/regimental?"*.

Eixo B: Direitos Fundamentais e Liberdade de Expressão

- **Incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" (Tema 786/STF)**: *"Excelência, no julgamento do Tema 786 da Repercussão Geral, qual foi a tese firmada pelo STF sobre a subsistência do chamado 'Direito ao Esquecimento' no ordenamento constitucional brasileiro? Há exceções?"*.
- **Colisão de Direitos e Proporcionalidade**: *"Como o magistrado deve proceder diante do conflito manifesto entre o direito à informação/liberdade de imprensa e os direitos à honra e à intimidade? Explique os subprincípios da adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito."*.

Eixo C: Controle de Convencionalidade e Status dos Tratados

- **Status dos Tratados de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade**: *"Doutor, qual é o status hierárquico dos tratados de direitos humanos no Brasil? Diferencie o rito do art. 5º, § 3º, da CF do rito ordinário. Em que consiste o controle de convencionalidade difuso que pode ser exercido pelo juiz de 1º Grau?"*.
- **Súmula Vinculante 25 e Prisão Civil**: *"Qual a natureza jurídica do afastamento da prisão civil do depositário infiel promovido pela Súmula Vinculante 25? Houve revogação do texto constitucional (art. 5º, LXVII) ou mera paralisia da sua eficácia?"*.

Eixo D: Incidente de Deslocamento de Competência (IDC) e Corte IDH

- **Requisitos e Legitimidade do IDC (art. 109, § 5º, CF)**: *"Quais são os requisitos constitucionais e jurisprudenciais exigidos para o deferimento do Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)? Quem possui legitimidade ativa para instaurá-lo e qual o órgão jurisdicional competente para o seu julgamento?"*.
- **Condenações do Brasil na Corte IDH e Deveres de Proteção**: *"Cite dois casos emblemáticos em que o Estado brasileiro foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e explique quais as medidas de não repetição decorrentes em matéria de segurança pública ou persecução penal."*.

3. As Pegadinhas e Armadilhas Mais Comuns da Banca

1. **Subsistência do "Direito ao Esquecimento" no Brasil**:
   - *A Pegadinha*: O examinador induz o candidato a defender que a pessoa que cumpriu pena penal tem o "direito ao esquecimento" de proibir a divulgação de fatos verídicos passados pela imprensa.
   - *A Solução*: **Tese superada e inconstitucional**. No julgamento do **Tema 786/STF**, a Suprema Corte fixou ser **incompatível com a Constituição Federal a ideia de um direito ao esquecimento** que permita proibir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados. Eventuais excessos ou abusos são analisados no caso concreto via indenização ou direito de resposta, mas sem censura prévia.
2. **Legitimidade Ativa para Instauração do IDC**:
   - *A Pegadinha*: A banca pergunta se o Juiz de Direito, a vítima ou o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) podem requerer diretamente ao STJ a federalização do processo via IDC.

- *A Solução*: **Não**. A legitimidade ativa para a instauração do Incidente de Deslocamento de Competência perante o STJ é **exclusiva do Procurador-Geral da República (PGR)** (*art. 109, § 5º, da CF*). Nenhuma outra autoridade ou particular possui capacidade postulatória para dar início ao incidente.

3. **Violação Oculta da Cláusula de Reserva de Plenário (Súmula Vinculante 10)**:
   - *A Pegadinha*: O examinador sustenta que um órgão fracionário de Tribunal (Câmara ou Turma) não violou a Reserva de Plenário porque não declarou formalmente a palavra "inconstitucional", apenas afastou a lei no caso concreto por interpretá-la conforme a Constituição.
   - *A Solução*: **Falsa premissa**. Nos termos da **Súmula Vinculante nº 10 do STF**, viola a Cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, **afasta sua incidência no todo ou em parte**.
4. **Revogação Constitucional da Prisão do Depositário Infiel**:
   - *A Pegadinha*: Afirmar que a aprovação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José) "revogou" ou "deletou" o trecho do artigo 5º, LXVII, da CF que previa a prisão do depositário infiel.
   - *A Solução*: O tratado internacional supralegal não tem o condão de revogar norma constitucional originária. O efeito promovido pela ratificação da CADH e cristalizado na **Súmula Vinculante 25** foi a **paralisação da eficácia infraconstitucional** das leis que regulamentavam a prisão do depositário infiel, tornando ilícita a sua decretação no direito interno.

4. Modelos de Respostas "Nota 1000" (Estruturadas em 4 Etapas)

Modelo A — Direitos Humanos (Incidente de Deslocamento de Competência - IDC)

Pergunta da Banca: *Excelência, discorra sobre o Incidente de Deslocamento de Competência (IDC). Quais são os seus requisitos constitucionais e jurisprudenciais, quem possui legitimidade para instaurá-lo e qual o órgão competente para julgá-lo?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, o **Incidente de Deslocamento de Competência (IDC)** é um instituto constitucional de tutela dos Direitos Humanos introduzido pela Emenda Constitucional nº 45/2004 e positivado no **artigo 109, § 5º, da Carta Magna**, por meio do qual se promove a federalização da investigação ou do processo penal com a transferência da competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal."
2. **Legitimidade e Órgão Julgador**: "A legitimidade ativa para a instauração do incidente é **exclusiva do Procurador-Geral da República (PGR)**, e o órgão constitucionalmente competente para processar e julgar o IDC é o **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**."
3. **Requisitos Constitucionais e Jurisprudenciais**: "Para o deferimento do IDC pelo STJ, exigem-se cumulativamente dois requisitos essenciais: 1) A demonstração da existência de **grave violação a direitos humanos** no caso concreto; e 2) A inequívoca comprovação da **incapacidade, inércia ou omissão das autoridades estaduais/locais** em promover a adequada persecução penal com a

devida diligência, gerando risco de responsabilização internacional do Estado brasileiro perante órgãos de proteção."

4. **Fechamento Institucional / Exemplificação**: "Cito como precedentes a procedência do IDC nº 2 pelo STJ no *Caso Manoel Mattos* (homicídio de defensor de direitos humanos em contexto de grupos de extermínio), e o indeferimento no *Caso Dorothy Stang* ante a efetiva atuação das instituições estaduais paraenses, demonstrando o caráter excepcional da medida."

Modelo B — Controle de Convencionalidade e Status dos Tratados (RE 466.343/STF e SV 25)

> **Pergunta da Banca**: *Candidato, qual o status hierárquico dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos incorporados ao ordenamento jurídico pátrio? Explique em que consiste o Controle de Convencionalidade exercido pelo magistrado de 1º Grau.*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, no sistema constitucional brasileiro, os Tratados Internacionais de Direitos Humanos possuem natureza de **normas constitucionais** (se aprovados pelo rito qualificado do art. 5º, § 3º) ou natureza de **normas supralegais** (se aprovados pelo rito ordinário), conforme tese fixada pelo STF no julgamento do **RE 466.343/SP**."
2. **Fundamentação Legal e Hierárquica**: "Os tratados aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, equivalem a **Emendas Constitucionais** (ex.: Convenção de Nova York sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e Tratado de Marraqueche). Já os demais tratados de direitos humanos ratificados anteriormente ou pelo rito ordinário situam-se no patamar de **supralegalidade**: postam-se abaixo da Constituição Federal, mas acima de toda a legislação ordinária infraconstitucional."
3. **Controle de Convencionalidade pelo Magistrado**: "Diante disso, opera-se o **Controle de Convencionalidade Difuso**, no qual qualquer magistrado ou tribunal, no exercício de sua jurisdição, deve paralisar a eficácia e afastar a aplicação de lei interna infraconstitucional que divirja ou viole tratado internacional de direitos humanos ratificado pelo Brasil. Exemplo emblemático foi o ajuizamento da **Súmula Vinculante nº 25 do STF**, que paralisou as normas infraconstitucionais reguladoras da prisão civil do depositário infiel ante o conflito com o artigo 7.7 do Pacto de San José da Costa Rica."
4. **Fechamento Institucional**: "Com efeito, o magistrado de 1º Grau aplicará a Teoria do Duplo Filtro de Validade Normativa, submetendo a lei infraconstitucional tanto ao filtro da conformidade constitucional quanto ao filtro da compatibilidade com a normativa internacional de Direitos Humanos."

Modelo C — Direitos Fundamentais (Incompatibilidade do "Direito ao Esquecimento" - Tema 786/STF)

> **Pergunta da Banca**: *Doutor, o ordenamento constitucional brasileiro assegura o "Direito ao Esquecimento" para impedir a divulgação jornalística de fatos verídicos passados relativos a condenações criminais antigas?*

Resposta "Nota 1000":

1. **Afirmação Direta**: "Excelência, a resposta é **negativa**. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do **Tema 786 da Repercussão Geral**, fixou a tese da **incompatibilidade do chamado 'Direito ao Esquecimento' com a Constituição Federal de 1988**."
2. **Fundamentação Constitucional**: "A pretensão de proibir a divulgação de fatos ou dados verídicos licitamente obtidos e publicados pela imprensa, com amparo exclusivo na passagem do tempo, esbarra nos vetores constitucionais da **liberdade de expressão, de imprensa e de informação** (artigo

5º, incisos IX e XIV, e artigo 220, caput e § 1º, da CF), bem como no direito coletivo à memória histórica."

3. **Ponderação de Direitos e Abusos**: "A Suprema Corte assentou que eventuais excessos ou abusos praticados na veiculação da matéria jornalística não autorizam a censura prévia nem o apagamento de dados verídicos passados, mas ensejam a devida reparação a posteriori mediante **direito de resposta proporcional ao agravo e indenização por danos materiais e morais** aos direitos da personalidade (artigo 5º, incisos V e X, da CF)."
4. **Fechamento Institucional**: "Assim, ao julgar ações fundadas em pretensão de desindexação ou proibição de matérias históricas, o magistrado indeferirá o pedido de limitação prévia da informação verídica, resguardando o direito de resposta ou reparação se demonstrado no caso concreto o dolo ou desvio abusivo da função jornalística."

5. Quadro Sintético de Atualizações Jurisprudenciais do Bloco 5

Tema	Entendimento Tradicional / Superado	Entendimento Atual e Esperado na Prova Oral
Direito ao Esquecimento	Aplicação do direito ao esquecimento para limitar a divulgação de fatos criminais passados.	**STF (Tema 786/RG)**: É **incompatível com a Constituição Federal** o direito ao esquecimento que permita proibir a divulgação de fatos verídicos licitamente obtidos.
Legítima Defesa da Honra no Júri	Tese defensiva aceita sob o manto da plenitude de defesa no Tribunal do Júri.	**STF (ADPF 779)**: Declarada **inconstitucional** por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da vida e da igualdade de gênero.
Cotas Raciais em Concursos (Lei 12.990)	Questionava-se a constitucionalidade de reservação de vagas e a abrangência da lei.	**STF (ADC 41 e ADI 7188)**: **Constitucional a reserva de vagas para negros** em concursos públicos, extensível às fases dos certames de forma proporcional.
Perda da Nacionalidade (EC 131/2023)	A aquisição de outra nacionalidade gerava perda automática da nacionalidade brasileira.	**STF e CF (EC 131/2023)**: A perda da nacionalidade **deixou de ser regra autônoma**, ocorrendo apenas se expressamente requerida pelo cidadão ou por sentença em fraude ao processo migratório.
Prescrição no Ressarcimento ao Erário	Discutia-se a imprescritibilidade ampla de ações de ressarcimento por improbidade.	**STF (Tema 897/RG)**: São **imprescritíveis apenas as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade** administrativa.